

상여금(경영성과급)의 법적 성격에 관한 연구*

- 일본과의 비교법적 고찰을 중심으로 -

이 정*

목 차

I. 문제의 소재
II. 임금의 법적 성격

III. 상여의 임금(성) 여부
IV. 비교법적 검토와 시사점

국문요약

상여금(경영성과급)이 임금에 해당하는지의 여부를 둘러싸고 논란이 많다. 어떤 금품이 임금에 해당하기 위해서는 사용자가 ‘근로의 대상’이라는 요건을 충족할 필요가 있다. 상여금의 법적 성격에 대해서는 종전부터 ‘공로 보상적 성격’을 비롯하여 ‘생활 보전적 성격’ 및 ‘임금 후불적 성격’ 등 다양한 해석이 이루어져온 만큼, 통일된 해석이 없었다. 그러던 중 최근에는 공기업의 경영성과급을 임금에 해당한다는 판결이 나오면서 통상임금에서 시작된 분쟁이 임금 전체로 전선을 확대하고 있는 형국이다.

한편 우리나라의 노동법제 및 임금체계와 비슷한 일본에서도 우리와 비슷한 고민을 하고 있는 듯하다. 예를 들어 일본의 노동기준법은 임금을 비롯하여 평균임금에 대한 정의규정을 두고 있으며, 산정기준도 매우 흡사하다. 또한 일본기업은 동계와 하계 연2회 상여금(경영성과급 포함)을 지급하고 있는데, 이를 노동의 대상인 임금으로 볼 것인가에 대해서는 이론(異論)이 있는 것도 사실이다.

이와 같이 일본에서도 상여금의 법적 성격에 대해서는 다양한 논의가 있음에도 불구하고, 이를 둘러싼 분쟁은 실무상 거의 발생하지 않고 있다. 그 이유는 무엇일까? 해답은 의외로 간단하다.

첫째는 일본에서는 우리나라와는 달리 통상임금 및 최저임금 산정 시에 1개월의 지급주기를 초과하는 임금에 대해서는 산정대상에서 제외하고 있다는 점이다. 둘째는 평균임금을 산정할 때 지급주기가 3개월을 초과하는 임금은 그 대상에서 제외하고 있으며, 대부분의 일본기업의 경우 이 주기를 초과하여 상여금을 지급하고 있기 때문에 그다지 문제가 되지 않는다.

다만, 일본에서는 상여금을 우리나라와는 달리 하계 및 동계로 2회에 나누어 지급하는 경우가 일반적이며, 경영성과급의 경우에도 상여금에 포함시켜 지급하는 경우와 이와는 별도로 지급하는 경우 등 매우 다양하다. 따라서 일본의 임금제도를 우리나라의 임금제도와 단순비교하기에는 한계가 있다. 그럼에도 불구하고 각종 임금을 둘러싼 실무상의 혼선을 방지하기 위해 산정 시에 일정한 지급주기를 설정하는 방식은 우리에게 많은 것을 시사해주고 있다고 생각한다.

* 이 연구는 2019학년도 한국외국어대학교 교내학술연구비의 지원에 의하여 이루어진 것임.

** 한국외국어대학교 법학전문대학원 교수, 법학박사

주제어: 임금, 평균임금, 일본의 임금제도, 임금의 개념, 상여금, 경영성과급, PI PS

I. 문제의 소재

상여금(경영성과급)이 평균임금의 산정기초가 되는 임금에 해당하는지의 여부를 둘러싸고 논란이 많다.¹⁾ 어떤 금품이 임금에 해당하기 위해서는 ‘근로의 대상’으로 지급될 것을 요한다, 다시 말해서 근로제공과 직접적 또는 밀접한 관계가 인정되어야만 임금으로 간주된다. 상여금의 경우에도 근로제공과의 대가관계가 있다면 임금으로 해석해도 무방하다. 그러나 상여금 중에는 은혜적 또는 보상적인 성격이 함께 포함되어 있는 경우도 있는데, 이러한 경우에도 ‘근로의 대상’인 임금으로 해석해야하는지가 문제로 된다.

한편 우리나라와 임금체계가 비슷한 일본의 경우를 보면, 일본에서도 상여금의 법적 성격을 둘러싸고 우리와 비슷한 문제로 고민을 하고 있는 듯하다. 일본에서는 통상 하계와 동계로 2회에 나누어 상여금(경영성과급 포함)을 지급하고 있는데, 일반적으로 기본급에 그 때 그 때의 상황에 따라 정해지는 계수에 지급대상기간의出勤을 및 성적계수를 곱하여 산정하기 때문에, 이를 노동의 대상인 임금으로 볼 것인가에 대해서는 이론(異論)이 있다.

상여금은 흔히 ‘공로 보상적 성격’을 비롯하여 ‘생활 보전적 성격’, ‘근로장려적 성격’ 및 ‘기업성적의 분배의 성격’ 등을 아울러 가지고 있는 것으로 해석하기 때문에 온전히 노동의 대상인 급료와는 그 성격을 달리한다. 그럼에도 불구하고 최근에는 이와 같은 상여금의 특수성을 배려하지 않고 임금으로 해석하려는 경향이 있다.

이에 본 연구에서는 위와 같은 문제의식을 가지고 일본과의 비교법적인 시각에서 상여금에 대한 법적 성격을 분석한 다음, 상여금(경영성과급)의 임금 해당(성) 여부에 대해 검토하고자 한다. 특히 일본에서는 평균임금이나 최저임금 산정 시에 상여(경영성과급)를 포함시킬 것인가의 여부를 둘러싸고 문제가 되고 있는 만큼, 이에 초점을 맞추어 분석하고자 한다. 다만, 일본에서는 상여금을 우리나라와는 달리 하계 및 동계로 2회에 나누어 지급하는 경우가 일반적이며, 경영성과급의 경우에도 상여금에 포함시켜 지급하는 경우와 이와는 별도로 지급하는 경우 등 매우 다양하므로 우리나라의 임금제도와 단순비교하기에는 한계가 있음을 밝혀둔다.

1) 최근에는 대법원이 공공기관의 ‘경영평가 성과급’에 대해 임금(성)을 인정한 사례(대법원 2018. 10. 12. 선고 2015두36157 판결 ; 대법원 2018. 12. 13. 선고 2018다231536 판결)를 계기로 상여금의 법적 성격에 관한 논의가 활발히 이루어지고 있다.

II. 임금의 법적 성격

1. 노동기준법

일본 민법(제623조)에 의하면 ‘고용’은 ‘당사자의 한쪽이 상대방의 노무에 종사하는 것’과 ‘상대방이 이에 대해 그 보수를 지불하는 것’을 대가관계로 한 계약으로 ‘노무에 종사하는 것’에 대한 ‘보수’가 기본적 요소로 되어 있다. 이 ‘보수’가 임금인데 이것을 노동기준법은 보다 정밀하게 “이 법률에서 임금이란 임금, 급료, 수당, 상여 그밖에 명칭 여하에 상관없이 노동의 대상(對償)으로서 사용자가 근로자에게 지불해야하는 것을 말한다.”라고 규정하고 있다(제11조).

이와 같이 일본의 노동기준법은 임금에 대해 ①사용자가 근로자에게 지급하는 것으로, ②노동의 대상이면, 그 명칭여하를 불문하고 임금으로 간주한다는 추상적인 규정을 두고 있을 따름이다. 따라서 어떤 급품이 노동기준법상의 임금에 포함되는지를 파악하기 위해서는 위의 두 가지 요건을 충족하고 있는지에 대한 면밀한 검토가 필요하다.

임금의 성격을 ‘노동의 대상’으로 이해하는 것은 ‘유상 쌍무계약’으로서의 근로계약에 비추어 타당한 것이라 할 수 있다. 따라서 상여금이 ‘노동의 대상’에 해당되는지의 여부는 상여금의 성질·내용에 비추어 개별적·구체적으로 판단할 것이 요구되는 임금의 판단요건인 ‘노동의 대상’은 실무상 매우 폭넓게 해석되고 있다.²⁾

따라서 행정실무에서는 구체적으로 무엇이 노동의 대상에 해당지가 아니라, 무엇이 노동의 대상에서 제외되는지를 구별하는 소위 ‘소거(消去)방식’으로 그 범위를 확정하는 수법을 사용하고 있다.³⁾

2. 행정해석

(1) 노동의 대상

‘임금’에 대한 행정해석을 보면, ‘노동기준법상의 임금 여부가 불명확한 경우, 이러한 급여가 단체협약이나 취업규칙 등에 명문으로 지급요건이 정해져 있는 경우에는 노동기준법상의 임금에 해당’하는 것으로 해석하는 경향이 있다. 다시 말해서, 사용자가 근로자에게 지급하는 급여의 지급요건이 단체협약이나 취업규칙 등에 의해 미리 지급조건이 명확하게 규정되어 있고, 그에 따라 사용자에게 지불의무가 있는 경우에는 ‘노동의 대상’으로 인정하는 것이다.

위의 행정해석에 의할 경우, 사용자가 근로자에게 지불하기로 약속한 모든 급여에 대하여 ‘노

2) 현행 근로기준법은 일본의 노동기준법과는 달리 임금을 근로의 ‘대가(對價)’라는 표현을 쓰고 있으나, 종전에는 일본과 마찬가지로 근로의 대상(對償)이라는 표현을 사용한 바 있다.

3) 荒木尚志, 『労働法』, 第3版, 有斐閣, 2016, 125頁.

동의 대상'으로서의 성격을 인정하는 결과가 되므로, 이에 대해서는 노동기준법상 임금의 개념을 지나치게 확대해석하게 된다는 비판이 있다.⁴⁾

이에 행정실무에서는 편의상 '노동의 대상'으로서의 임금과 구별되어야 할 것으로 '임의적·은혜적 급여', '복리후생 급여' 및 '기업설비·업무비'라는 세 개의 개념을 규정한 다음, 상여금을 포함한 급여가 여기에 해당하는 경우에는 노동기준법상의 '임금'에 해당하지 않는 것으로 해석해오고 있다.

1) 임의적·은혜적 급여

우선 '임의적 은혜적 급여'에 해당하면 노동의 대상인 임금으로 해석되지 않는다. '임의적 은혜적 급여'의 전형적인 것으로 결혼 축의금, 병문안에 따른 위로금, 근친자 사망 시 조위금 등의 경조사비적 성격의 급여 등이 있다. 단, 이러한 급여라도 단체협약, 취업규칙 등에 의해 미리 지급조건이 명확하게 규정되어 있는 경우에는 노동과 직접적인 대응관계에 없더라도 넓은 의미에서 노동의 대상이라고 파악하여 임금으로 간주한다.⁵⁾

퇴직금(퇴직수당)이나 상여금(일시금)은 지급할지 여부 및 어떠한 기준에서 지급하는지 등이 오로지 사용자의 재량에 의하는 경우에는 임의적 은혜적 급여로써, 임금이 아니다.⁶⁾ 그러나 오늘날의 대다수 퇴직금과 같이 단체협약, 취업규칙, 노동계약 등에서 이에 대한 지급여부 및 지급기준을 정하고 있으며, 사용자에게 지불의무가 있는 것은 임금으로 인정된다.⁷⁾

상여의 경우에도 단체협약과 취업규칙 등에서 그 지급시기와 금액의 결정방법 등을 정하고 있고, 그에 따라 각 시기에 결정·지급되는 것이라면 임금으로 해석된다. 그러나 사용자의 재량으로 지급하는 경우에는 임금에 해당되지 않는다.

2) 복리후생급여

'복리후생급여'는 사용자가 노동대상으로서가 아니라 근로자의 복리후생을 위해 지급하는 이익 또는 비용이므로 개념상 임금이 아니다. 전형적인 복리후생급여로는 자금대부, 금전급여, 주택대여 등이 있다.

그밖에 회사의 샤워시설, 스포츠시설, 레크리에이션 시설 등 종업원의 공동이용 시설도 복리후생급여에 해당한다. 가족수당과 주택수당은, 임금규정 등으로 제도화되어 있는 한, 임금에 해당하는 것으로 해석된다.⁸⁾

4) 예에 대해서는 노동기준법 제11조의 '노동의 대상'이라는 요건을 경시한 해석이라는 비판이 있다. 상세한 것은 津曲藏之丞, 「賃金」, 『(旧)労働法講座』, 第5巻, 1158頁.

5) 1947. 9. 13 發基17호.

6) 광고사회의 영업사원에 대한 '장려금'의 일부를 이 기준으로부터 임금이 아니라고 한 판례로서 中部日本廣告社事件, 名古屋高判平2. 8. 31, 『労働民事判例集(労民集)』, 41권 4호, 656頁.

7) 1947.9.13.發基17호, 住友化學事件, 最3小判昭43.5.28, 『判例時報(判時)』, 519호, 89頁.

8) ユナイテッド航空事件, 東京地判平13. 1. 29, 『労働判例(労判)』 805호, 71頁.

3) 기업설비·업무비

기업이 업무수행을 위해 부담하는 기업시설과 업무비는 노동의 대상으로서의 임금이 아니다. 예를 들어 작업복, 작업용품대, 출장비용, 사용(社用)교제비, 기구손료(損料) 등이 이에 해당한다.⁹⁾

또한 통근수당이나 현물지급으로서의 통근정기권은 통근비용이 노동계약의 원칙으로부터 말하면 근로자가 부담해야 할 것으로 업무필요경비가 아니지만, 그 지급기준이 정해져 있는 한 임금으로 해석된다.

(2) 사용자가 근로자에게 지불하는 것

노동기준법상의 ‘임금’이 제2요건은 ‘사용자가 근로자에게 지불하는 것’이다. 이 요건에 대해 문제가 되는 전형적인 예는, 여관(호텔), 음식점(레스토랑) 등에 있어서 손님이 종업원에게 주는 팁인데, 이것은 손님이 지불하는 것인 까닭에 원칙적으로 임금은 아니다(단, 그러한 종업원이 팁만으로 생활하고 있는 경우에는 팁 수입을 받을 수 있는 영업시설을 사용하는 이익이 임금이 되는 경우가 있다).

이에 대해 레스토랑과 바 등에서 손님이 지불하는 급사봉사료(서비스료)가 당일 노동(서비스)을 한 근로자에게 기계적으로 분배되는 경우에는 사용자가 지불하는 것이라고 할 수 있다.

또한 종업원이 사망한 경우에 유족에게 지급하는 사망퇴직금의 경우에는 통상 유족이 직접 청구권을 가지게 된다. 다시 말해서 사망퇴직금은 근로자에게 지급되는 것이 아니기 때문에 임금에는 해당되지 않는다.¹⁰⁾

(3) 소결

임금은 근로자에게 있어 유일한 생활의 양식이기 때문에 노동보호법규로서는 이를 되도록 넓고 명확하게 파악하는 것이 바람직하다. 그러나 임금의 개념에 대해 명확한 규정을 두고 있는 입법례는 드물다. 뿐만 아니라 현실적으로 지불되고 있는 임금의 종류 또한 매우 다양하기 때문에 구체적으로 무엇이 임금에 해당하는지를 파악하는 것 자체가 매우 곤란한 경우가 많다.

이에 노동기준법상의 임금의 정의를 단지 ① 사용자가 근로자에게 지불하는 것으로, ② 노동의 대상이면, ③ 그 명칭의 여하를 불문한다고 추상적으로 규정하고 있을 뿐, 근로자에게 지불하는 특정 임금이 본조에서 말하는 임금에 해당하는지의 여부는 구체적 해석에 의하여 결정되게 된다.¹¹⁾

9) 제복에 대해서는 1948. 2. 20 基發 297호.

10) 日本貿易振興會事件. 最一小判昭和55.11.27, 『民集』, 34卷 6号 815頁.

11) 일본에서 임금을 정의하는 방식은 우리나라와 대단히 유사하다고 할 수 있다. 즉, 일본 노동기준법 제11조는 “이 법률에서 임금이란 임금, 급료, 수당, 상여 기타 명칭 여하와 무관하게 노동의 대상으로서 사용자가 근로자에게

3. 학설 및 판례

임금의 개념과 함께 확인해야 할 것이 바로 임금의 법적 성격에 관한 이론이다. 임금의 법적 성격은 곧 임금의 본질이 무엇인가라는 질문이라고 할 수 있다. 임금의 법적 성격은 법 이론적 전개에서 임금청구권의 발생근거 내지 시기에 관해 어떻게 현실과 결부시켜 이를 이론적으로 설명할 것인가의 문제이다.¹²⁾ 특히, 임금의 법적 성질에 관한 논의는 근로의 대가를 어떠한 법적 근거에 의해서 확정할 것인가를 중심으로 견해의 대립이 있다.

임금의 법적 성질에 관한 이론적 논의는 주로 일본 학계를 중심으로 시작되어 우리나라에서의 논의에 영향을 주었으며, 임금의 판단에 대한 우리나라 대법원의 해석론적 기초를 제공하고 있다고 생각한다.

(1) 학 설

1) 노동대가설

‘노동대가설’은 근로계약을 근로와 임금의 교환관계로 보고 근로제공의 대가로 임금이 지불하는 관계로 보는 견해이다.¹³⁾ 이 견해는 근로자의 구체적인 근로가 현실적으로 행해질 때 비로소 근로계약상의 사용자와의 합의를 근거로 임금청구권이 근로자에게 발생한다고 본다(임금의 후불성).¹⁴⁾

노동대가설은 보수의 지급에 대한 민법의 일반규정을 그 배경으로 한다. 우리 민법 제656조 제2항은 “보수는 약정한 시기에 지급하여야 하며 시기의 약정이 없으면 관습에 의하고 관습이 없으면 약정한 노무를 종료한 후 지체 없이 지급하여야 한다.”고 규정하고 있다. 노동대가설은 이 규정에서 ‘노무를 종료한 후’라는 문언을 임금은 근로의 대가로서 근로가 현실적으로 이루어진 이후에야 사용자에게 청구할 수 있다는 의미로 해석하게 된다.

따라서 노동대가설은 근로자가 사용자로부터 받는 일체의 금품 중에서 현실적으로 제공한 근로에 대한 대가만이 임금이라는 점에서 현실적인 근로제공과 관련이 없는 금품은 임금에 해당하지 않는다고 본다. 즉, 근로계약상 노무이행의 임금지급과 쌍무유상의 대가적 견련관계에 있다는 것으로 민법 제655조와 근로기준법 제2조 제1항 제5호의 반대해석으로 실정법상 근거가 없는 무노동무임금원칙의 근거로 활용되기도 한다.¹⁵⁾

지불해야 하는 것을 말한다.”고 규정하고 있다. 그리고 우리와 같이 평균임금과 통상임금을 구분하여 규정하고 그 산정 방법도 우리와 매우 비슷하다. 다만, 통상임금에 관하여 우리의 근로기준법시행령 제6조 제1항과 같이 정기성, 계속성, 일률성 등을 요구하는 구체적인 정의규정은 없다.

12) 이병태, 「최신노동법」, (주)중앙경제, 2008, 690면.

13) 下井隆史, “賃金の労働力説を批判する”, 『季刊労働法』, 97(1975)号, 120頁.

14) 園部季信, “爭議行爲と民事上の免責”, 『労働法大系3, 爭議行爲』, 1963, 90頁 以下; 柳川眞佐夫外, 判例労働法の研究(下巻), 1961, 1160頁.

15) 김상률, 「임금 개념과 제도상 문제점에 관한 연구」, 경북대학교 법학전문대학원 박사학위논문, 2011, 39면.

노동대가설을 대표하는 판례는 일본의 ‘묘조전기(明星電氣)사건’이다. 해당 사건에서 판례는 “원고들은 우선 노동임금은 구체적 노동에 대한 대가가 아니고 근로자가 노동력을 사용자의 지배에 맡기는 것에 대한 대가이며, 즉 사용자의 처분권 하에 노동력이 놓여 진다는 사실에 의하여 임금청구권이 발생한다고 하는 견해에 입각하여, 본 건에서 원고들의 노동력은 회사의 지휘 명령 하에 놓여 있기 때문에 임금청구권이 발생하였다고 주장한다.

그러나 근로계약은 민법의 고용계약보다 발전하고 노동법에 의하여 각종의 수정은 가해졌지만, 고용에 있어서의 ‘노무’에 대한 ‘보수’라고 하는 쌍무유상계약으로서의 기본적 성격은 근로 계약에 있어서 ‘근로’에 대한 ‘임금’으로 승계되었다고 말할 수 있다.

따라서 근로계약의 이행으로서 구체적 근로가 있을 때 비로소 임금청구권이 발생하는 것이고 노동력을 사용자에게 맡기는 것은 계약이행의 한 과정으로 취해진 것에 지나지 않는다고 해석하는 것이 바람직하다.”¹⁶⁾고 한 바 있다.

2) 노동력대가설

‘노동력대가설’은 임금을 근로의 대가로 보지 않고, 사용자에게 자신의 노동력을 일정 시간 동안 처분할 것을 맡긴 것에 대한 대가로 보는 견해다. 이 견해는 근로가 ‘종속노동’이라는 점에서 출발한다. 근로자의 근로행위는 사용자의 지휘·감독을 받아서 이루어져야하기 때문에 근로 계약이라는 것은 근로 그 자체의 제공을 약속한 것이 아니라 일정한 조건 하에서 노동력의 처분 권한을 사용자에게 주는 계약으로 파악하는 것이 정당하다는 논리적 전개에 따른 결론이라고 말할 수 있다.¹⁷⁾

노동력대가설을 지지했던 대표적인 판결로서 일본의 ‘국철무로란사건(國鐵室蘭棧橋事件)’을 들 수 있다. 해당 사건에서 판례는 다음과 같이 판시 한 바 있다.

“원래 근로계약이란 피용자가 그 노동력을 일정기간 사용자의 처분에 위임하고 사용자의 지휘에 좇아 근로를 제공할 것을 약정하고 사용자는 노동력의 대가로서 임금을 피용자에게 지급할 것을 약정함으로써 성립하는 계약이므로 임금청구권은 피용자가 사용자의 지배권 내에 들어가고 그 노동력을 사용자의 처분에 위임하는 것, 즉 직장편입에 의하여 발생한다고 해석하여야 하며, 일단 노동력이 직장에 편입된 이상 피용자가 현실적으로 채무의 본질에 좇아 노무에 종사하지 않더라도 그것이 피용자의 귀책사유에 해당하는 경우를 제외하고는 임금청구권을 상실하지 않는다.”

이러한 노동력대가설에 따르면, 임금의 본질적인 성격은 민법의 고용이 규정하는 것과 같은 구체적 노동에 대한 대가가 아니라 추상적인 노동력의 제공에 대한 대가로 본다.

따라서 임금의 본질을 노동력 처분을 사용자에게 맡긴 것에 대한 대가로서 이해한다는 점에

16) 前橋地裁 1963. 11. 1. 판결.

17) 이 학설은 종래 일본의 다수설이었는데, 片岡昇, 本多淳亮, 山本吉人 등의 학자가 이 학설을 지지하였다.

서 노동대가설에 비하여 임금 개념의 범위가 넓다고 할 수 있다. 노동력대가설의 입장에서는 근로자의 근로의무가 추상적인 노동의 대가와 견력관계에 있는 것이므로 근로자가 소정시간 계속하여 자기의 노동력을 사용자의 지휘명령 하에 두으로써 실제로 노동이 행해지지 않더라도 임금 청구권이 발생할 수 있게 된다. 따라서 이 견해는 휴업수당, 가족수당 등 구체적인 근로의 제공과 관련이 없는 여러 수당에 대하여 노동대가설이 설명할 수 없는 부분을 설명할 수 있다는 장점이 있다.

노동력대가설은 노동대가설의 대안으로서 등장하였으며, 일본 및 우리나라의 판례에도 상당한 영향을 미친바 있다. 하지만 이 노동력대가설에 대하여는 경제학적인 개념인 노동력의 개념을 매개 없이 법률해석학에 끌어들었다는 비판이 있다.¹⁸⁾ 노동대가설은 노동력대가설과 표현의 차이를 보일 뿐 실질적 차이가 없다고 보는 견해도 있다.¹⁹⁾

또한 노동력대가설은 노동력제공의무는 근로계약의 복합적 구조에 대응하여 두 개 부분으로 구분된다고 본다. 즉, 근로자가 자기 노동력을 계속적으로 제공해야 할 지위에 두는 것, 다시 말하면 종업원인 지위의 설정이라는 측면과 이 지위에 입각해서 매일 소정의 시간동안 자신의 노동력을 사용자의 처분에 맡기는 측면과의 복합적인 구조를 갖게 된다. 그리하여 그 각각의 측면의 의무에 대응하여 임금청구권도 이면적으로 발생하게 된다는 것이다. 이런 법리적 입장에서 노동력대가설은 후술하는 임금이분설로 발전을 도모하게 된다.

3) 임금이분설

‘임금이분설’은 근로계약의 본질을 근로자의 지위를 취득하게 하는 신분계약의 성격과 근로의 제공에 대한 대가로서 일정한 보수의 지급을 약정하는 교환계약의 성격을 동시에 지닌 것으로 파악하여 임금은 이원적으로 구성되어 있다고 보는 견해이다.

이 견해에 따르면 노동대가설은 근로에 대한 직접적인 대가라고 할 수 없는 각종 상여금과 수당 등에 대한 설명을 충분하게 해주지 못하고 있고, 노동력대가설은 종속노동의 개념을 도입함으로써 임금의 범위를 넓혔다는 공적은 인정할 수 있지만 종속노동의 개념 자체가 변화하고 있는 현실에 있어서 여전히 유효하게 작용할 수 있을 것인가 하는 의문이 남는다.

임금이분설은 그와 같은 노동대가설과 노동력대가설의 한계에 대하여, 임금을 구체적 근로와 직접 결부되어 있는 교환적 임금 부분과 그렇지 않은 보장적 임금 부분으로 구분한 것이다. 임금이분설은 근로관계를 특별한 채권관계로 파악하여, 임금을 근로계약에 있어서 고정적 부분을 이루는 보장적 임금과 변동적 부분을 이루는 교환적 임금으로 구분한다.²⁰⁾ 다시 말해서 근로계

18) 김영문·이상윤·이정, 『임금개념과 평균임금·통상임금의 산정범위』, 법문사, 2004, 31면.

19) 임종률, “파업기간 중 임금지급에 관한 대법 판결”, 『노동법학(제6호)』, 한국노동법학회, 1996, 32면.

20) 이 학설은 일본의 峯村光郎교수가 처음으로 주장을 하였고, 이후 일본의 판례가 취하는 기본적인 입장이 되었다. 그러나 1981. 9. 18. 최고재판소 판결에서는 “파업기간중의 임금삭감의 대상으로 되는 부분의 존부 또는 이 부분과 임금삭감의 대상으로 되지 않는 부분의 구별은 당해 단체협약 등의 정함 또는 노동관행의 취지에 비추어 개별적으로 판단하는 것이 상당하다”고 판시하면서 추상적·일반적 임금이분설을 배척하고 당사자의 의사를

약은 일정한 기업에서 근로자의 지위를 취득할 목적으로 사용자와 근로자간에 체결된 계약(일종의 신분적 계약)으로 이는 근로계약에 있어서 소위 고정적 부분을 이루며, 다른 한편으로는 근로계약은 근로자의 노동의 제공에 대하여 사용자가 그 대가로서 임금의 지급을 약정하는 계약(단순한 채무계약)으로서 이는 근로계약에 있어서 소위 변동적 부분을 이룬다는 것이다.

이 견해에 따르면, 근로계약의 체결에 의하여 근로자가 부담하는 제1차적 의무는 약정한 기일에 기업조직 내에 들어와 종업원의 지위를 취득하고 직무를 개시하는 것이다. 또한 이 의무를 이행함에 따라 근로계약 체결 시에 추상적으로 발생한 임금채권의 일부분은 이 단계에서 구체적인 청구권으로 전환되며, 이와 같은 임금부분은 종업원이라고 하는 지위에 대하여 지급되는 성질의 것이고 종업원에 대한 생활보장의 의미가 포함된 소위 ‘보장적 임금’이라고 한다. 대체로 가족수당, 통근수당, 별거수당, 물가수당 또는 학력, 근속, 연령 등 전통적인 연공서열형 임금이 여기에 해당한다고 본다.

반면, 근로계약에 의하여 근로자가 부담하는 제2차적 의무는 개개의 노동력을 사용자의 처분에 맡기고 그 상태를 일정한 시간을 유지해야 하는 것인데, 제2차적 의무를 이행함에 따라 임금청구권은 전면적으로 발생한다고 본다. 이와 같은 임금부분은 실제의 근로의 제공에 대응하여 지급되는 것으로 보아 이를 소위 교환적 임금이라고 한다. 대체로 정근수당, 근무성적급, 직무급, 직능급, 특수작업수당 등이 여기에 해당한다고 본다.²¹⁾

우리나라 대법원은 종전에 파업기간 중의 무노동 무임금 원칙의 적용과 관련하여 다음과 같이 임금이분설의 입장을 취한 바가 있다.

“쟁의행위로 인하여 사용자에게 근로를 제공하지 아니한 근로자는 일반적으로 근로의 대가인 임금을 구할 수 없다 할 것이지만, 구체적으로 지급청구권을 갖지 못하는 임금의 범위는 임금 중 사실상 근로를 제공한 데 대하여 받는 교환적 부분과 근로자로서의 지위에 기하여 받는 생활보장적 부분 중 전자 만에 국한된다. 임금 중 교환적 부분과 생활보장적 부분의 구별은 해당 임금의 명목에 불구하고 단체협약이나 취업규칙 등의 규정에 결근 지각 조퇴 등으로 근로를 제공하지 아니함에 의하여 해당 임금의 감액을 정하고 있는지의 여부, 또는 위와 같은 규정이 없더라도 종래부터 관행이 어떠하였는지 등을 살펴 판단하여야 한다.”²²⁾

이러한 임금이분설에 의하면, 사용자는 파업기간 동안 구체적 근로의 제공에 따른 교환성 임금은 지급할 의무는 없지만, 보장성 임금은 지급해야 한다는 논리적 결과가 된다. 사용자는 근로자를 조직에 편입시키고 유지해야 하므로, 이러한 종속적 근로관계를 유지하기 위한 성격의 급여의 지급이 필요하게 되며, 이는 직접적인 근로의 대가와 결부된 것은 아니지만 간접적으로는 근로관계와 결부되어 지급되는 것이므로 이 역시 임금에 해당한다고 한다.²³⁾ 우리나라에서 임금

우선시하고자 노력한 바 있다.

21) 이철수, 『임금에 관한 법리』, 한국노동연구원, 1993, 11면.

22) 대법원 1992. 3. 27. 선고 91다36037 판결.

이분설은 현실적으로 근로제공이 없는 경우, 특히 쟁의행위 시 근로자에게 임금을 지급할 수 있는 이론적 근거로 기여한 바가 크다고 평가된다.²⁴⁾

4) 의사해석설

임금이분설에 대한 비판으로 소위 의사해석설이 등장하였다. ‘의사해석설’은 임금의 범위는 노사의 약정인 단체협약, 취업규칙, 근로계약, 노사관행에 따라 정해지고 노무불이행(결근)에 대한 임금공제문제는 노사의 의사해석의 해석문제라고 보는 견해이다.

특히, 의사해석설은 파업에 의한 임금의 삭감문제와 관련하여 파업 시 임금은 해당 근로계약의 내용으로서 파업에 의해 결근하더라도 공제하지 않는 임금부분을 정하고 있는지의 여부에 대한 계약해석의 문제이며, 임금과 근로계약의 본질론에서 임금은 두 개 부분으로 나누어진다는 해석은 적절하지 않다고 비판하였다.²⁵⁾

일본에서는 최근 이러한 비판이 대두됨에 따라 최고재판소도 “해당 단체협약 등의 규정이나 노동관행의 취지에 비추어 개별적으로 판단하는 것을 상당하다고 하여...이른바 추상적 일반적 임금이분론을 전제로 하는...주장은 적절치 못하다”라고 판시하면서, 파업 시 임금 삭감에 대해서도 “가족수당의 삭감이 임금규칙(취업규칙)의 규정에 근거하여 약 20년 간 이루어지고, 임금규칙에서 그 규정이 삭제된 후에도 세부 취급 중에 정해져 계속적으로 이의 없이 시행되어 왔다는 사실관계에서는 가족수당은 스트라이크에 의한 임금삭감의 대상이 된다.”²⁶⁾고 보아 의사해석설의 입장을 취한 바 있다.

의사해석설의 입장에서는 소위 재량근로의 경우에도, 사용자의 입장에서는 노동조합과의 협정으로 파업의 경우 노무가 제공되지 않은 범위의 인정방법을 명확히 해둘 필요가 있다고 한다. 또한 재량근로가 성과주의 임금체계 하에서 운영되고 있는 성과급의 경우에는 임금삭감과 비슷한 문제가 발생할 수 있으므로, 결근의 경우의 취급과 더불어 파업의 경우의 임금 취급을 단체협약 등에 따라 명확히 해둘 필요가 있다고 한다.²⁷⁾

(2) 우리나라 판례의 입장

우리나라의 대법원도 과거 일본 판례의 영향을 받아 파업기간 동안이라 하더라도 사용자는 근로자에게 ‘보장성 임금’을 지급해야 한다는 취지로 임금이분설의 입장에서 임금의 법적 성질을 파악한 바 있다.²⁸⁾ 그 후 대법원은 1995년 전원합의체 판결로 견해를 바꾸어 기존의 임금이

23) 김지형, 『노동법해설』, 청림출판, 1993, 129-130면.

24) 이병태, 『최신노동법』, (주)중앙경제, 2008, 718면.

25) 下井隆史, 『雇用關係法』, 191頁. 이하 참조.

26) 三菱重工業事件, 最二小判 昭56.9.18, 『民集』 35卷 6号, 1028頁.

27) 菅野和夫, 『労働法(第9版)』, 2010, 653~654頁 참조.

28) 대법원 1992. 3. 27. 선고 91다36037.

분설을 폐기하고 노동대가설에 따라 임금의 법적 성질을 파악하는 입장을 취한 후 현재까지 유지하고 있다.

1995년 해당 대법원 전원합의체 판결 중에서 이에 관한 부분을 인용하면 다음과 같다.²⁹⁾

“모든 임금은 근로의 대가로서 ‘근로자가 사용자의 지휘를 받으며 근로를 제공하는 것에 대한 보수’를 의미하므로 현실의 근로 제공을 전제로 하지 않고 단순히 근로자로서의 지위에 기하여 발생한다는 이른바 생활보장적 임금이란 있을 수 없고, 또한 우리 현행법상 임금을 사실상 근로를 제공한 데 대하여 지급받는 교환적 부분과 근로자로서의 지위에 기하여 받는 생활보장적 부분으로 2분할 아무런 법적 근거도 없다. 뿐만 아니라 임금의 지급 실태를 보더라도 임금은 기본적으로 근로자가 생활하는 데 필요한 생계비와 기업의 지불능력과 상관관계에 따라 형성되는데 임금을 지불항목이나 성질에 따라 사실상 근로를 제공한 데 대하여 지급받는 교환적 부분과 현실의 근로 제공과는 무관하게 단순히 근로자로서의 지위에 기하여 받는 생활보장적 부분으로 나누고(이른바 임금2분설) 이에 따라 법적 취급을 달리하는 것이 반드시 타당하다고 할 수도 없고, 실제로 현실의 임금 항목 모두를 교환적 부분과 생활보장적 부분으로 준별(峻別)하는 것은 경우에 따라 불가능할 수 있으며, 임금2분설에서 전형적으로 생활보장적 임금이라고 설명하는 가족수당, 주택수당 등도 그 지급 내용을 보면 그것이 근로시간에 직접 또는 비례적으로 대응하지 않는다는 의미에서 근로 제공과의 밀접도(密接度)가 약하기는 하지만 실질적으로는 근로자가 사용자가 의도하는 근로를 제공한 것에 대하여 그 대가로서 지급되는 것이지 단순히 근로자로서의 지위를 보유하고 있다는 점에 근거하여 지급한다고 할 수 없으며, 이러한 수당 등을 지급하게 된 것이 현실의 근로 제공과는 무관하게 단순히 근로자의 생활이나 지위를 보장하기 위한 것이라고 할 수도 없으므로, 이러한 수당 등을 현실적인 근로 제공의 대가가 아닌 것으로 보는 것은 임금의 지급 현실을 외면한 단순한 의제(擬制)에 불과하다.”

이와 같은 대법원의 판례는 당사자의 계약의사를 중심으로 임금성 여부를 판단하되, 그 판단이 불분명한 경우에는 보충적으로 노동대가설에 따라서 임금의 개념을 결정한다는 입장에서 있는 것으로 평가된다.³⁰⁾ 이러한 대법원의 견해에 대하여는, 근로계약을 채권계약으로 파악하고 근로계약의 사회법적 규제를 완화하려는 경향이 인식의 기저에 깔려있다는 비판이 있다.³¹⁾

(3) 소 결

노동대가설은 구체적으로 제공한 근로의 대가만을 임금으로 본다는 점에서 근로기준법의 임금 규정과 현실의 임금체계를 효과적으로 설명하기 어려운 측면이 있다. 또 임금의 개념적 범주가 다소 협소해지게 되어 근로조건의 보호라는 노동법의 입법목적을 충분하기 실현하기에 일정

29) 대법원 1995. 12. 21. 선고 94다26721 전원합의체 판결.

30) 김유성, 『노동법(Ⅰ)』, 법문사, 2005, 77면.

31) 이흥재, “대법원의 근로관계 인식에 대한 조명 - 민주헌정 이후 시민법적 인식으로의 회귀 및 지속의 평가 -”, 『법학(124호)』, 서울대학교 법학연구소, 2002, 207면.

부분 한계가 있다.

노동력대가설이나 임금이분설은 현행법상 유급주휴일 또는 휴업수당 등과 같이 구체적 근로를 제공하지 않아도 일정한 임금이 보장되도록 하는 규정이 있을 뿐 아니라 기본급 이외에도 가족수당, 자녀학자금 보조비 등의 각종 생활보장적 임금이 일반화되어 있는 현실을 감안하여 기존의 노동대가설의 한계를 극복하기 위하여 새롭게 등장한 이론이라고 할 수 있다.

비록 현재 대법원이 노동대가설의 입장에 있기는 하지만, 근로의 대상의 외연을 꾸준히 확대해 온 판례의 궤적을 살펴보면, 노동력대가설이나 임금이분설적 사고가 현재의 임금 개념을 판단하는데 있어서 많은 영향을 끼친 것은 부인할 수 없는 사실이라고 할 수 있다.³²⁾

임금의 법적 성질에 관한 이상의 이론적 논의들은 임금의 개념을 설정하고 구체적인 임금해당성을 판단함에 있어 각각의 의의가 있다고 생각한다. 그러나 우리나라의 임금체계와 구성항목의 실태는 매우 복잡하고 다양하기 때문에 임금의 법적 성격에 따라 연역적 방법으로 ‘근로의 대상성’ 유무를 일률적으로 결정하는 것은 어려운 일이다. 또한 판례나 행정해석을 통해 임금의 개념을 판단하는 일정한 법리가 형성되어 왔기 때문에, 임금의 법적 성질에 대한 이론적 논의와 실무적 판단간의 연관관계는 점차 약화되고 있는 실정이다.

따라서 임금의 개념 설정과 구체적인 판단을 일반론적인 이론이나 법원의 해석에 의존하는 것은 다소 한계가 있다고 여겨지며, 임금 개념의 안정적인 해석과 판단을 위해서 법적 이론과 판례 그리고 행정지침 간의 동일성을 구축해 나가는 노력이 필요하다고 생각된다.

Ⅲ. 상여의 임금(성) 여부

1. 상여의 법적 성격

(1) 상여의 개념

1) 상여란?

일본에서는 사용자가 근로자에게 매월 고정적으로 지급하는 월례 임금과는 별도로 1년에 몇 차례(통상적으로는 하계(6월)와 동계(12월)에 2번), 보너스나 일시금의 명목으로 상여를 지급하는 사례가 많이 존재한다. 이러한 일시금을 일반적으로 ‘상여’ 또는 ‘보너스’라고 한다. 상여는 에도(江戸)시대에 큰 상점의 주인이나 지배인이 종업원에게 명절인 추석(일본에서는 이를 ‘오봉(お盆)’이라 함)이나 연말에 계절에 따라서 새 옷을 해 입게 하거나 용돈을 주는 습관이 있었는데 그것이 유래된 것이라고 한다.³³⁾

32) 김유성, 『노동법(Ⅰ)』, 법문사, 2005, 78면.

이와 같은 상여는 월례임금과 같이 ‘근로의 대가’로서 사용자에게 지급이 의무화되어 있는 것은 아니다. 근로계약은 사용자와 근로자의 합의에 의하여 성립되는 것이라는 점에서, 상여를 어떠한 목적으로 지급할지 여부는 원칙적으로는 사용자와 근로자간의 합의에 의하게 된다. 상여는 일반적으로 ① 기업실적의 이익 배분적 성격, ② 근로자의 공로 보상적 성격, ③ 향후 근로의욕의 고취, 근로에 대한 기대로서의 성격, ④ 생활 보전적 성격, ⑤ 임금의 후불적 성격을 가지는 것으로 해석된다.

이처럼 상여는 다양한 성격을 가지고 있지만, 이러한 성격 가운데 어느 성격이 강한지의 여부는 각 기업의 상여제도의 실태에 따라서 다르다. 그리고 판례도 “상여는 근로의 대가인 가치를 가지는 것은 부정할 수 없지만, 임금과 같이 근로계약상 당연히 사용자에게 지급이 의무화되어 있는 것은 아니고 대상기간 동안 사용자의 수익이나 근로자의 근무상황, 근무태도 등 많은 요소를 고려하여 지급의 유무나 그 금액이 결정되는 것으로, 사용자의 이익의 배분이나 근로자에 대한 보장적(報獎的) 성질도 강하여 그 성격은 일의적으로 설명할 수 있는 것은 아니다”³⁴⁾고 하고 있으며, 각각의 제도설계에 따라서 상여가 다양한 성격을 가지는 것으로 인식되고 있다.

참고로 상여의 성격에 대한 행정해석을 보면, “정기 또는 임시로 원칙적으로 근로자의 근무성적에 따라 지급하는 것으로, 그 지급액이 사전에 확정되어 있지 않는 것을 말하며, 정기적으로 지급되고 그 지급액이 미리 확정되어 있는 것은 그 명칭에 상관없이 상여로 보지 않는다.”고 해석하고 있다.³⁵⁾

2) 상여청구권의 성질

일본에서 상여금을 지급하는 경우에 취업규칙(급여규정)이나 단체협약에 상여에 대한 규정이 두고 있으며, 그 기재내용이 노사 간의 상여에 관한 계약내용으로 되어 있는 것이 일반적이다. 이 경우 규정이 정하는 방법에 따라서 근로자가 취득하는 청구권의 성질이 달라질 수 있다. 예를 들어 상여의 지급액까지 근로계약 내용으로 되어 있는 경우에는 사용자가 지급의무를 지며, 근로자는 사용자에게 대하여 지급을 청구할 수 있다. 이러한 권리를 ‘구체적 청구권’이라고 한다.

문제는 단체협약이나 취업규칙 등에서 단순히 상여를 지급한다는 취지의 추상적 규정을 두고 있는 경우, 구체적인 지급율과 지급액이 사전에 확정되어 있지 않는 경우에도 상여청구권이 발생하는지의 여부이다. 이에 대해 판례는 지급률 및 금액에 대해 사용자의 결정 또는 노사 간의 합의가 없으면 구체적인 청구권은 발생하지 않는다는 견해가 확립된 법원칙이다.³⁶⁾ 이러한 권리를 ‘추상적 청구권’이라고 한다.

33) 퇴직금도 에도시대의 ‘분점 차려주기(のれん分け)’에서 유래된 것이라고 한다.

34) 錦タクシー事件, 大阪地判, 1996(平8). 9. 27, 労判717-95.

35) 昭和 22. 9. 13 発基17号.

36) ヤマト科学事件, 東京地判昭58.4.20, 『労働判例』, 407号, 17頁: 清風会光ヶ丘病院事件, 山形地酒田支決昭, 63.6.27, 『労働判例』, 524号 54頁.

3) 상여지급에 관한 규정을 두고 있는 경우

가. 지급 유무 및 지급액이 매번 결정되는 케이스

상여는 사전에 지급액을 확정되지 않는 것이 일반적이다. 예를 들어 ‘회사업적이 현저하게 저하된 경우나 기타 부득이한 사유가 있는 경우에는 지급일을 변경하거나 지급하지 않을 수도 있다’는 등과 같이 회사의 사정에 따라 지급여부를 유보한 다음, 매번 제반 사정을 고려한 뒤 결정한다는 취지를 정하고 있는 것이 일반적이다.

또한 상여지급의 결정방법이나 고려요소를 ‘업적, 능력, 근무성적, 근무태도’ 등을 기재하여 보다 상세하게 취업규칙(상여규정)이나 단체협약 등에 따라 정하는 경우 및 그 하위 규범에서 정하는 케이스도 많이 존재한다.

그러나 중소기업을 중심으로 ‘상여는 년 2회, 업적에 따라 지급한다’는 것과 같이 보다 추상적인 규정을 두고 있는 경우도 있는 등 지급시의 판단요소, 금액의 결정방법 등이 불명확한 케이스도 있다. 이러한 경우 상여의 구체적인 금액이나 지급기준(해당 기준에 의해 일의적으로 지급액이 결정되는 기준)이 결정될 때까지는 상여의 구체적 청구권은 발생하지 않으며, 근로자는 상여의 추상적 청구권을 취득하게 된다.

나. 지급액이 사전에 결정되어 있는 케이스

상여의 구체적인 금액이나 지급기준이 이미 확정되어 있는 경우, 근로자는 사용자의 지급액의 결정절차를 기다릴 필요 없이 소정의 지급일에 구체적 청구권을 취득하게 된다. 또한 지급액이 확정되어 있는 케이스로서는 이미 확정된 연봉금액의 일정 비율을 상여로 나누어 지급하는 케이스와 월급제+고정상여의 케이스 등이 있다.

다. 지급 유무가 명확하지 않은 케이스

‘상여는 회사의 업적 등에 따라 지급할 수도 있다’는 것과 같이, 상여를 지급할지의 여부 및 지급하는 경우에 얼마나 지급할지의 여부가 사용자의 재량에 의하는 경우가 있다. 이러한 케이스에서는 사용자가 상여지급의무를 지지 않는다. 이때 근로자는 사용자가 상여의 지급을 결정하고, 그 구체적 지급액이 확정될 때까지는 구체적으로도 추상적으로도 청구권을 취득하고 있지 않는 것이 된다.

4) 상여의 임금성

상여는 그 지급조건이 취업규칙 등에서 명확히 규정되어 있는 경우, 해당 규정에 근거하여 지급되는 금품은 ‘근로의 대상’으로서 노동기준법상의 임금(노동기준법 제11조)이 된다. 따라서 위의 ①, ②의 케이스에서는 상여의 지급조건을 취업규칙 등에서 명확히 하고 있다고 할 수 있으므로 노동기준법상의 임금이라고 할 수 있다.

한편, 앞의 ③의 케이스에서는 그 지급자체를 사용자가 임의로 결정할 수 있기 때문에 임의적·은혜적 급부라고 할 수 있으며, 노동기준법상의 임금이라 볼 수 없다.³⁷⁾ 다시 말해서 근로계약상 상여로 지급하도록 하고 있는 모든 금품이 노동기준법상의 ‘임금’에 해당하는 것은 아니다. 다만, 노동기준법에 의해 보호되는 ‘임금’에 해당되지 않는다고 해도 세법상은 사용자가 근로자에게 지급하는 것은 넓게 급여소득으로 간주된다. 현물로 상여를 대신하는 것도 노동기준법 제24조의 규제(통화불의 원칙)의 대상외이기 때문에 가능하게 되지만, 그러한 경우 그 현물지급에 의한 ‘경제적 이익’이 급여소득이 된다.

(2) 상여의 노동기준법상 성격

1) 매월 1회 이상 일정기일 지급의 원칙

노동기준법상의 ‘임금’은 매월 1회 이상, 일정 기일을 정하여 지급해야 하지만(노동기준법 제24조 제2항), ‘상여’에 대해서는 매월 1회 이상 일정 기일 지급의 원칙은 적용되지 않는다(노동기준법 제24조 제2항 단서). 또한 노동기준법 시행규칙 제8조는 ‘1개월 이상 기간의 출근성적에 의해 지급되는 정근수당’, ‘1개월 이상 일정기간의 연속근무에 대하여 지급되는 근속수당’, ‘1개월 이상 기간에 걸친 사유에 의해 정산되는 격려금(獎勵加給) 또는 능률수당’은 노동기준법 제24조 제2항 단서의 규정에 의한 임시로 지급되는 임금이나 상여에 준하는 것으로 열거하고 있다.

문제는 노동기준법상 ‘상여’에 관한 구체적인 정의가 없는 관계로 해석상의 논란이 있다. 이에 대해 행정통달은 정기 또는 임시로, 근로자의 근무성적에 따라서 지급되는 것으로, 그 지급액이 사전에 확정되어 있지 않은 것을 노동기준법 제24조의 ‘상여’라고 보고 있다. 따라서 정기적으로 지급되고 또 그 지급액이 확정되어 있는 것은 명칭의 여하에 관계없이 상여라고 볼 수 없으며, 노동기준법 시행규칙 제8조에 해당되지 않는 것은 동법 제24조 제2항의 규정에 따라서 매월 지급되어야 하는 것으로 하고 있다.³⁸⁾

위의 통달을 전제로 하면, 연봉제에서 연봉액을 16분할하여 16분의 1씩을 월례 임금으로서 지급하고 나머지 16분의 4를 하계와 동계에 16분의 2씩 지급하는 경우나, 월급제에서의 고정상여(②케이스의 경우)는 매월 1회 이상 일정 기일 지급의 원칙의 적용을 받게 되어 해당 상여의 지급방법은 노동기준법에 위반되어 30만원 이하의 벌금에 처해질 가능성이 있다(노동기준법 제120조 제1항).

하지만 이러한 해석에 의할 경우, 고정적으로 상여를 지급하는 것은 언제나 노동기준법에 반하는 것으로 될 수 있다는 점에서 현실적인 타당성이 다소 부족한 부분이 있다. 이 점에 대하여 통달의 ‘상여’에 관한 정의를 전제로, 연봉제상의 상여가 매월 1회 이상 일정 기일 지급원칙의

37) ‘실적 등에 의해’라고 규정되어 있어도, 실적이 좋으면 반드시 지급한다는 의무가 발생하고 있는 것은 아니다.

38) 1947(昭22). 9. 13, 發基17号.

적용을 받는 것은 지나치게 형식적인 법 해석이므로 연봉제에 대해서는 동조의 적용을 부정해야 한다는 견해가 있다.³⁹⁾

또한 결론은 찬성이지만 ‘상여’에 관한 통달은 1947(昭22)년의 것으로 고정적으로 지급되는 상여라는 것을 별로 상정하고 있지 않던 시대라는 점에서, 현재의 ‘상여’에 관한 정의로서는 적절하지 않다는 견해도 있다. 연봉제 또는 상여의 고정지급은 상여지급액이 사전에 정해져 있지 않은 경우보다도 오히려 근로자에게 이익이 된다고 할 수 있는 측면이 있고, 그러한 상여의 지급방법이 형벌의 대상이 되는 것도 타당하지 않다. 이러한 논지에서는 노동계약상의 상여로서 1개월을 초과하는 기간마다 지급되는 노동기준법상의 임금으로서의 성질을 가지는 금품에 대해서는 제24조 제2항 단서의 상여로서 다루는 것이 타당하다고 해석할 수도 있다.

2) 할증임금의 산정기초

할증임금을 산정할 경우에 가족수당, 통근수당(이상 노동기준법 제37조 제5항), 별거수당, 자녀교육수당, 주택수당, 임시로 지급되는 임금, 1개월을 초과하는 기간마다 지급되는 임금(이상 노동기준법 시행규칙 제21조)은 제외된다. 또한 ‘1개월을 초과하는 기간마다 지급되는 임금’이란 1개월을 초과하는 기간마다 지급되는 ‘상여’ 등이 이에 해당된다.

상여는 해고가 자유롭지 못한 일본의 고용사회에서 기업의 업적변동에 따라서 연간 임금을 변동시키는 시스템으로서 채택되어 왔다. 연수입은 12개월분을 기본으로 하여 설정하고 업적이 좋으면 월급의 5개월분 정도의 상여가 지급되어 연간 월급의 약 17개월분 정도에 달한다. 이 5개월분은 변동적인 것으로 대부분의 기업에서는 취업규칙 등에 ‘업적에 따라 지급’한다는 등으로 규정하여 구체적인 상여지급 책무를 지지 않는 수단을 취해왔다. 따라서 상여는 변동적인 임금이기 때문에 할증임금의 산정기초에서 제외하는 것으로 취급해왔다.

한편, 통달에서는 연봉제에서 매월 지급부분과 상여부분을 합계하여 사전에 연봉액이 확정되어 있는 경우에 상여로 지급되고 있는 부분은 ‘상여’에 해당하지 않고, ‘임시로 지급되는 임금’ 및 ‘1개월을 초과하는 기간마다 지급되는 임금’의 어느 것에도 해당되지 않기 때문에 할증임금의 산정기초에서 제외할 수 없다고 해석하고 있다.⁴⁰⁾

이러한 산정에 대하여 연봉제는 사전에 연간 임금액을 확정된 다음 그 지급방법에서 연봉을 16등분하여 일부를 상여로 지급하는 것이기 때문에 1개월을 초과하는 기간마다 지급되는 임금이라고는 볼 수 없다고 하는 것은 다소 형식적인 해석이라는 비판이 있다. 왜냐하면 고정성이 있는 금액이라는 이유로 할증임금의 산정기초에 산입하게 되면 사용자는 상여임금의 고정을 피하는 방향으로 임금정책을 설정할 가능성이 있어, 오히려 근로자의 이익이 저해될 수도 있기 때문이다. 따라서 금액이 고정되어 있는 상여의 경우에도 ‘1개월을 초과하는 기간마다 지급되는 임금’에 해당되고, 할증임금의 산정기초에서 제외될 수 있다는 점도 충분히 고려될 필요가 있다.

39) 土田道夫, 『労働契約法』, 有斐閣, 2008, 267頁.

40) 2000(平12). 3. 8, 基収78號.

3) 평균임금의 산정기초액

평균임금의 산정기초가 되는 ‘임금의 총액’에서 ‘임시로 지급된 임금’, ‘3개월을 초과하는 기간마다 지급되는 임금’, ‘통화이외의 것으로 지급된 임금’이 제외된다. ‘3개월을 초과하는 기간마다 지급되는 임금’이란, 연간 2회의 상여 등이 이에 해당된다.⁴¹⁾

그러나 통달에서는 사전에 연봉이 확정되어 있는 연봉제에서 평균임금의 산정에 대해서는 할증임금의 산정과 비슷하게 해석하고, 상여부분을 포함한 연봉의 12분의 1을 1개월 임금으로서 평균임금을 산정하는 것이라고 해석하고 있다.⁴²⁾

4) 취업규칙으로의 기재

취업규칙의 기재사항을 규정하고 있는 노동기준법 제89조는 제2호에서 절대적 필요기재사항으로서 ‘임금’을 규정하고 있지만, 이 ‘임금’에서는 ‘임시적인 임금 등’을 제외하고 있다. 그리고 동조 제4호가 ‘임시적인 임금 등’에 대하여 ‘규정을 하는 경우’는 ‘이에 관한 사항’을 절대적 필요기재사항으로 하고 있다. 상여는 이 ‘임시적인 임금 등’에 해당된다(노동기준법 제24조 제2항 단서, 노동기준법 시행규칙 제8조). 따라서 상여에 대하여 어떠한 규칙을 마련하는 경우는 그 규칙을 취업규칙에 기재할 필요가 있다.

또한 행정해석에 의하면 “상여에 대해서는 그 성격상 지급액에 대하여 규정하는 것이 어려울 것이지만, 그 지급이 제도로서 확립되어 있는 것이라면 지급조건, 지급시기 등에 대해서 규정하여야 한다.”고 하고 있으며, 위의 ③의 케이스와 같이 지급의 유무나 금액이 사용자의 재량에 맡겨져 있는 경우는 그 취지를 기재하면 충분하다.⁴³⁾

2. 경영성과급의 임금(성)

일본에서는 위의 ‘기본상여(또는 정기상여)’와는 별개로 전사적으로나 개인이 목표이익을 초과하거나 달성했을 때 ‘업적상여(경영성과급)’를 지급하는 경우가 있다.⁴⁴⁾

경영성과급은 흔히 유럽과 미국 기업에서 볼 수 있는 제도로, 근로자의 동기부여를 촉진하는 업적분배시스템으로서 **Profit Sharing Bonus**(pay back)와 **Incentive Bonus** 등이 대표적이다. 일본 기업에서도 기본상여와는 별개로 ‘결산상여(기말상여)’⁴⁵⁾와 ‘보장금(報獎金)’ 제도⁴⁶⁾를 도입·운용하고 있는 곳이 많은데, 거의 같은 취지의 속하는 것으로 해석된다.

41) 일본에서는 우리와는 달리 할증임금 및 최저임금 산정 시에 ‘1개월을 초과하는 기간마다 지급되는 임금’은 제외하고 있다.

42) 2000(平12). 3. 8, 基収78号.

43) 厚生労働省労働基準局編, 「2010(平成22)年版, 労働基準法(下)」.

44) 경영성과급을 일본에서는 ‘업적상여’ 또는 ‘결산상여’라고도 하며, 보통 3~4월에 지급한다.

45) 결산상여로 지급하는 경우, 결산일까지 모든 지급 대상자에게 지급액을 통지한 다음, 결산일로부터 1개월 이내에 지급하는 조건을 충족하지 않으면, 당기의 손금(損金)으로 인정되지 않는다.

46) 보장금(報獎金)제도란, 매출액 등의 영업실적에 따라 인센티브를 지급하는 제도를 말한다.

이 중 Profit Sharing Bonus는 목표이익(영업이익 또는 경상이익)을 초과했을 때에 전사적으로 지급되는 것을 가리키는 경우가 많지만, Incentive Bonus는 목표로 하는 매출액(또는 매출 총이익)을 달성했을 때에 부문이나 개인에 대해서 지급되는 경우가 많다. 그렇기 때문에, Profit Sharing Bonus는 이익 환원의 의미가 강하고, 결산상여에 가까운 성격을 가지는 것에 반해, Incentive Bonus는 일본의 보장금 제도에 해당한다.

이러한 경영성과급의 법적 성격과 관련하여 임금(성) 여부가 문제로 될 수 있다. 이에 대해서는 기본상여에 대한 임금(성) 지표에 준하여 판단하면 된다. 다시 말해서 경영성과급의 지급조건을 취업규칙 등에서 명확히 하고 있는 경우에는 노동기준법상의 임금이라고 할 수 있으나, 그 지급자체를 사용자가 임의로 결정할 수 있는 경우에는 임의적·은혜적 급부라고 할 수 있으므로 노동기준법상의 임금이라 볼 수 없다.

다만, 일본에서의 경영성과급의 지급방식은 매우 다양하여, 기본상여처럼 정기적으로 지급하는 경우가 있는가 하면, 특별상여의 형태로 지급하는 경우도 있다. 또한 일본에서는 평균임금 산정 시에 ‘3개월을 초과하는 기간마다 지급되는 임금’은 제외하도록 노동기준법에서 정하고 있다는 점에 유의할 필요가 있다(동법 제37조 제5항, 동법 시행규칙 제21조). 따라서 일본에서는 상여(경영성과급 포함)를 매월 지급하지 않는 한 평균임금을 비롯하여 할증임금(통상임금)이나 최저임금 산정 시에 상여의 임금(성) 여부는 별로 문제가 되지 않는다.

IV. 비교법적 검토와 시사점

위에서 검토한 바와 같이 일본의 임금법제는 우리나라와 거의 대동소이하나, 실제로 이를 적용함에 있어서는 양국 간의 임금체계의 차이 등으로 인하여 상당히 달리 해석하고 있음을 알 수 있다.

첫째, 임금에 관한 규정을 보면, 일본의 노동기준법은 ‘노동의 대상’으로 ‘사용자가 근로자에게 지불하는 것’으로 정의하고 있는데(제11조), 이는 우리나라 근로기준법(제2조 제1항 제5호)이 ‘근로의 대가’로 ‘사용자가 근로자에게 지불하는 일체의 금품’과 동일한 뜻으로 해석된다. 다만, 일본에서는 행정실무의 편의상 ‘노동의 대상’으로서의 임금과 구별되는 것으로 ‘임의적·은혜적 급여’, ‘복리후생 급여’ 및 ‘기업설비·업무비’라는 세 개의 개념을 규정한 다음, 상여금을 포함한 급여가 여기에 해당하는 경우에는 노동기준법상의 ‘임금’에 해당하지 않는 것으로 해석해오고 있다. 하지만, 이 경우에도 단체협약이나 취업규칙 등에서 지급시기·금액의 결정방법 등을 정하고 있는 경우에는 임금으로 해석하고 있는데, 이점에서도 우리나라와 크게 다르지 않다.

둘째, 일본의 노동기준법은 해고예고수당이나 휴업수당, 업무상재해보상 등을 산정하기 위해 평균임금에 관한 규정(제12조)을 두고 있는데, 그 산정기준으로 ‘산정사유가 발생하기 이전의 3개월간에 지불된 임금 총액을 같은 기간의 총일수로 나눈 금액’으로 규정하고 있다. 이 또한 우리

나라의 근로기준법상의 평균임금에 관한 규정(제2조 제1항 제6호)과 동일하다. 다만, 평균임금의 산정방식에 있어서는 양국 간에 다소 차이를 보이고 있다. 우선 일본에서는 평균임금은 근로자의 생활보장이 목적이므로 근로자의 통상적 생활임금을 기준으로 산정하며, 임시로 지급된 임금(퇴직금, 사상병수당 등), 3개월 초과한 기간으로 지급되는 임금(상여, 수당 등), 통화이외의 것으로 지급되는 임금 등은 제외하도록 하고 있다(제12조 제4항).⁴⁷⁾ 이점에서는 우리나라와 별반 다르지 않다. 그러나 상여금에 대한 평균임금 산정방식에서는 일본에서는 이를 평균임금에서 제외하고 있는데 비해, 우리나라에서는 사유발생일 이전 1년간 받은 총액을 12개월로 나누어 3개월에 해당하는 임금을 포함시키는 것이 판례의 입장이다.⁴⁸⁾ 참고로 일본에서는 우리나라와는 달리 통상임금 및 최저임금 산정 시에 1개월의 지급주기를 초과하는 임금에 대해서는 산정대상에서 제외하고 있다.⁴⁹⁾

셋째, 상여 및 성과급에 대해서는 양국 모두 이에 대한 명확한 법적 근거를 두고 있지 않으므로, 각종 수당산정을 둘러싸고 이들에 대한 임금(성) 여부가 종종 문제로 등장한다. 따라서 상여 및 성과급이 임금에 해당되는지의 여부는 단체협약이나 취업규칙, 근로계약 등과 같은 자치규범 및 노사관행 등을 고려하여 개별적으로 판단할 수밖에 없다고 판단된다. 다만 일본에서는 전통적으로 상여를 연 2회(동계 및 하계) 지급하며 생활 보전적 성격 이외에도 공로보상적 성격과 기업성적의 분배의 성격 등이 포함되어 있으므로 전형적인 임금인 급료와는 달리 인식되어 왔다. 그러나 점차 산업화·국제화가 진행되면서 다양한 형태의 상여가 생겨났으며, 최근에는 경영성과급을 지급하는 경우도 늘어나고 있다. 이와 더불어 상여 및 경영성과급에 대한 임금(성) 여부를 둘러싼 문제가 종종 발생하지만, 우리와 같이 크게 문제가 되지는 않는 것 같다. 그 이유는 예를 들어 일본에서는 평균임금을 산정할 때 지급주기가 3개월을 초과하는 임금은 그 대상에서 제외하고 있으므로, 대부분의 일본기업에서 지급하는 상여금(동계 및 하계 2회)은 이 주기를 초과하여 지급하고 있으므로 그다지 문제가 되지 않는다. 이는 통상임금 및 최저임금 산정 시에도 마찬가지인데, 여기서도 1개월 주기를 초과하여 지급하는 임금은 산정대상에서 제외되므로 상여 및 성과급에 대한 임금(성) 여부를 둘러싼 논쟁이 발생할 여지가 적다. 다시 말해서 일본에서는 상여나 성과급에 대한 지급기준이 취업규칙 등에 명확하게 규정되어 있는 경우, 해석상 임금에 해당하지만 평균임금 산정의 대상에서는 제외된다. 한편 우리나라의 경우에는 최근의 하이닉스 사건⁵⁰⁾에서 노사합의안 등에서 성과급(PI 및 PS)에 대한 지급기준, 지급률 등을 구체적으로 정하고 있다고 하더라도, 그때그때의 상황에 따라 그 지급기준이 변동되는 것이라면 ‘근로의 대상인 임금’으로 볼 수 없다고 판시한 바 있는데, 이는 어떤 의미에서 일본보다 임금의 개념을 더 좁게 해석하고 있는 것으로 보인다.

47) 상여가 당해 연도의 임금에 포함되어 사전에 확정되어 있는 연봉제의 경우에는 상여도 총액에 포함.

48) 대법원 1978. 2. 14. 선고 77다3121 판결; 대법원 1984. 4. 11. 선고 87다카2901 판결.

49) 일본 노동기준법 제37조제5항 및 동법시행규칙 제21조, 최저임금법 제4조 제3항 참조.

50) 수원지방법원 2020. 1. 31. 선고 2019가단50590 판결.

■ 참고문헌

- 荒木尚志, 『労働法』. 第3版, 有斐閣, 2016.
- 下井隆史, “賃金の労働力説を批判する”, 『季刊労働法』, 97号, 1975.
- 園部季信, “爭議行爲と民事上の免責”, 『労働法大系3-爭議行爲』, 1963.
- 菅野和夫, 『労働法』, 第12版, 弘文堂, 2019.
- 土田道夫, 『労働契約法』, 有斐閣, 2008.
- 西谷 敏, 『労働法』. 有斐閣, 2008.
- 厚生労働省労働基準局賃金時間課 編著, 『平均賃金の解説』, 労働調査会, 2004.
- 厚生労働省労働基準局編, 「2010(平成22)年版, 労働基準法(下)」.
- 柳川眞佐夫外, 『判例労働法の研究(下巻)』, 1961, 1160頁.
-
- 권 혁. “임금의 개념으로서 근로 대가성 판단에 관한 소고”, 『노동법포럼』, 제28호, 2019.
- 김유성, 『노동법(I)』, 법문사, 2005.
- 김영문·이상운·이정, 『임금개념과 평균임금·통상임금의 산정범위』, 법문사, 2004.
- 김지형, 『노동법해설』, 청림출판, 1993.
- 박지순·이상익, 『통상임금의 이해』, 신조사, 2013.
- 이병태, 『최신노동법』, (주)중앙경제, 2008, 690면.
- 이 정, 『한·일 비교를 통한 임금법제 이론과 실무』, 법문사, 2013.
- 이철수, 『임금에 관한 법리』, 한국노동연구원, 1993.
- 이흥재, “대법원의 근로관계 인식에 대한 조명-민주헌정 이후 시민법적 인식으로의 회귀 및 지속의 평가 -”, 『법학(124호)』, 서울대학교 법학연구소, 2002.

논문투고일 : 2020. 05. 07.
심 사 일 : 2020. 05. 08.
심사완료일 : 2020. 05. 20.

■ Abstract

A Study on the Legal Characteristics of Bonus (PI, PS)

- Focusing on Comparative Study with Japan -

Lee John*

There is much controversy over whether bonuses (PI, PS) amount to wages. In order for any money to be a wage, employers need to meet the requirement to be ‘object of work’. As for the legal nature of bonuses, there has been no unified interpretation of the legal nature of bonuses, as various interpretations have been made since the past, including “the nature of merit compensation,” “the nature of life preservation,” and “the nature of wage payment.” In the meantime, a dispute that started with regular wages has been expanding to the entire wage since the recent ruling that the bonuses of public corporations amounts to wages.

Meanwhile, Japan, which is similar to Korea’s labor legislation and wage system, seems to have similar concerns. For example, Japan’s Labor Standards Act has definition of average wages, including wages, and the calculation standards are very similar. In addition, Japanese companies pay bonuses twice a year—in winter and summer, and it is true that there is a theory about whether to regard them as wages subject to labor.

As such, despite various discussions in Japan on the legal nature of bonuses, disputes over them have rarely occurred in practice. Why is that for? The answer is surprisingly simple.

The first is that unlike Korea, wages exceeding one month’s payment cycle are excluded from the calculation list in Japan. Second, when calculating average wages, wages that exceed three months’ pay cycle are excluded from the list, and for most Japanese companies, bonuses are paid in excess of that cycle, so that is not a problem.

However, in Japan, bonuses are generally paid twice—in summer and winter, which are different from Korea, and in the case of management incentives, they are included in bonuses and paid separately. Therefore, there is a limit to simply comparing Japan’s wage system with Korea’s wage system. Nevertheless, I think the method of setting a certain payment cycle at the time of calculation to prevent confusion in practice over various wages suggests a lot to us.

Key Words: wage, average wage, wage system in Japan, concept of wage, bonus, productivity incentive, profit sharing

* Professor of Law School, Hankuk University of Foreign Studies

